

1501201-09.2022.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR VIEIRA PEREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

IGOR VIEIRA PEREIRA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501201-09.2022.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501201-09.2022.8.26.0510 - 2022/000317

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR VIEIRA PEREIRA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

IGOR VIEIRA PEREIRA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 28 de abril de 2.022, por volta das 17:00 horas, na Rua Jacutinga, nº 1530, Jardim Cidade Azul, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 40 (quarenta) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 34,1 gramas, 13 (treze) microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente, totalizando peso líquido aproximado de 5,2 gramas, e 12 (doze) invólucros plásticos contendo também a mesma substância entorpecente, na forma de crack, totalizando peso líquido aproximado de 3,98 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, laudo de constatação de fls. 21/23 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 54/56, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 15 de julho de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser majorada em decorrência da recidiva, com o afastamento do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo ser cumprida em regime prisional inicial fechado, incidindo, por fim, a pena de perdimento sobre os valores apreendidos.

Já a ilustre Defensora Pública sustentou insuficiente a prova produzida, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, pugnou pela desclassificação do delito atribuído inicialmente ao acusado para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, já que não especifica a recidiva, operando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional aberto, inclusive por força do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, facultando-se a interposição de recurso em liberdade, bem assim promovendo-se a restituição dos valores apreendidos.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, os entorpecentes indicados na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 54/56, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em juízo, o acusado afirmou que na ocasião dos fatos, dirigiu-se ao local onde acabou abordado, reconhecidamente por ser lá um ponto de venda de entorpecente, ocasião em que adquiriu de terceiro algumas porções de cocaína, recebendo de troco a quantia de dezoito reais. Quando aquele indivíduo que lhe vendeu a droga se afastou, subiu na árvore onde viu que ele mantinha o entorpecente, com vistas a subtraí-lo, momento em que foi abordado por Policiais Militares, negando que estivesse realizando o comércio ilícito naquele local. Observou que não indicou aos Policiais Militares a quem pertencia o entorpecente porque não é “cagueta” e porque é sabido o que ocorre com quem assim age.

Entretanto, a versão deduzida pelo acusado, de per si inidônea, ainda foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares ouvidos, reiterando em juízo o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de venda de entorpecente, quando notaram que o acusado, portando uma sacola, ao notar a aproximação da guarnição, subiu rapidamente em uma árvore, procurando se esconder. Diante desta circunstância, acabou sendo abordado, apreendendo-se com ele um maço de cigarro em cujo interior haviam porções de crack e cocaína e ainda a quantia de dezoito reais, tendo ele deixado pendurada em um galho a referida sacola, que foi também apreendida, tendo igualmente em seu interior várias porções daquelas mesmas substâncias entorpecentes, então admitindo que estava realizando no local o comércio ilícito e que o dinheiro decorria desta atividade ilícita.

Como se tem reiteradamente exposto, à míngua de qualquer elemento probatório que indique algum abuso, não se pode presumir que os policiais militares estivessem animados do propósito de incriminar indevidamente o acusado. Sobre isto: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372). E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Como se vê, além da idoneidade que gozam os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, cuidaram em exibir à d. Autoridade Policial o entorpecente que disseram apreendido em poder do acusado, além da mencionada sacola que ele portava para a acondicioná-lo. E a versão do acusado, como dito, revela-se inverossímil, até mesmo pelo que cuidou em dizer sobre as consequências que lhe adviriam se estivesse mesmo animado do propósito de subtrair o entorpecente que o traficante estaria mantendo no local, que não cuidou em identificar.

As circunstâncias, portanto, buscando o acusado se esconder sobre uma árvore, mantendo consigo várias porções de cocaína e crack, além de uma outra quantidade maior destas mesmas substâncias entorpecentes, no interior de uma sacola, que também procurou esconder no momento de sua abordagem, tudo isso em local onde reconhecidamente se realizava o tráfico, possibilitam seguro juízo de convicção sobre destinação mercantil da droga, inclusive com a apreensão com ele de certa quantia em dinheiro, cuja origem não demonstrou, por isso incidindo sobre a mesma a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, possível seja a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

A pena base, no entanto, deve ser agravada em 1/6 (um sexto) em função da recidiva (fls. 28), não se exigindo que seja específica, totalizando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Por fim, diante do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, a recidiva também afasta objetivamente a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", Lei nº 11.343/06 e artigo 61, inciso I, do Código Penal, CONDENO o acusado IGOR VIEIRA PEREIRA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, deve ser considerado a reincidência, como também a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código

Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não apenas em função da natureza hedionda do delito, mas também em função da recidiva, inviabilizando-se a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

A propósito: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA